

1500334-13.2022.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada à ré encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-13.2022.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-13.2022.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116311/2022 - DEL.POL.GUAPIARA, 24630318 -

DEL.POL.GUAPIARA, 2116311 - DEL.POL.GUAPIARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELINA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de CELINA DE OLIVEIRA, já devidamente qualificada nos autos, em decorrência da suposta prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Segundo consta na denúncia (fls. 120-122), no dia 29 de abril de 2022, por volta de 09:00 horas, na Rua Major Justino Ferreira Lima, nº 76, Centro, na cidade de

Guapiara, nesta comarca, CELINA guardava e tinha em depósito para fins de entrega ao consumo de terceiros, 08 papérolas de maconha pesando 17 gramas, e 08 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 3,60 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, a Polícia Civil recebeu informações de que a ré estaria promovendo o tráfico de drogas no endereço supracitado, disfarçando o comércio de entorpecentes com a venda de bebidas alcoólicas, mais precisamente, "copão". Daí que, a D. Autoridade Policial representou pela concessão de mandado de busca e apreensão, deferido nos autos nº 1500305-60.2022.8.26.0123.

Na data em questão, policiais cumpriram a ordem. A vistoria foi realizada na presença de CELINA, encontrando-se os entorpecentes acima referidos, além duas balanças de precisão e de máquina cartão, a quantia de R\$ 717,45.

Considerando as circunstâncias do caso, notadamente as denúncias pretéritas, bem como o efetivo encontro de drogas e a forma pela qual estavam embaladas, resta claro para o Ministério Público que a ré comercializava entorpecentes.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 127-129, seguindo-se a regular citação da ré às fls. 165, com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 186).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas à vítima, as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu, diante da confissão, a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a fixação do regime aberto e sua colocação em liberdade.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada à ré encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 11-16), auto de exibição/apreensão (fls. 20-22), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 23), laudo pericial das drogas (fls. 139-150, 155-162, 167-170), positivos para cocaína e maconha, laudo pericial dos materiais e do celular da ré (fls. 205-225) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que a ré, interrogada em solo policial disse que: em relação as drogas encontradas em seu guarda-roupa informa que a declarante e sua filha Gleysla são usuárias de drogas; a maconha e os eppendorf contendo cocaína são para seu uso e de sua filha; indagada sobre quem seria o fornecedor das drogas a declarante não quis se manifestar; sobre as balanças de precisão, a seladora plástica, os saquinhos plásticos apreendidos em sua residência, esclarece que são utilizados para fabricar salgados e doces. (fls. 07).

Interrogada em juízo, disse que: confessa que vendia drogas para sustentar o vício. A testemunha Fernando Hipólito Magalhães, policial civil, em juízo relatou que: é Policial Civil lotado na Delegacia de Polícia de Guapiara; na data em questão, com o apoio de Polícias Militares da cidade, se dirigiram até a Rua Major Justino Ferreira de Lima, nº 76, centro de Guapiara; as equipes foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela r. 2ª Vara da Comarca de Capão Bonito, nos autos nº. 1500305-60.2022.8.26.0123; por volta das 08:45, chegaram até o local dos fatos; chamaram pela proprietária da residência; foram recepcionados pela Sra. CELINA DE OLIVEIRA, que teve ciência do inteiro teor do mandado e das razões daquela diligência; a ré acompanhou todas as buscas, foram vistoriados vários

cômodos da residência; na cozinha do imóvel e na sala, estava armazenadas uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, copos descartáveis, canudos e outros utensílios; indagada a ré, informou que comercializa bebidas em sua residência, contudo não tem autorização da Prefeitura Municipal para funcionar, por tal motivo, fizeram contato com o setor responsável do órgão municipal que compareceu até o local e tomou as medidas administrativas cabíveis; na área externa da residência, nada de ilícito foi encontrado; chamou a atenção foi a existência de um cartaz afixado na entrada da residência onde estava um cardápio de venda de bebidas alcoólicas com os respectivos preços cobrados; em prosseguimento, no cômodo central da sala, na cozinha, no quarto dos fundos e no banheiro, nada de ilícito foi encontrado; quando foi realizar as buscas no quarto em que a ré dorme, dentro do armário, mais precisamente dentro de um pé de meia, logrou êxito em localizar 08 papелotes de maconha, todos envoltos com embalagem plástica e prontos para a venda; ainda dentro do armário, foram localizadas e apreendidas duas máquinas de precisão e de cartão, além da quantia de R\$717,45(setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) em dinheiro trocado com várias moedas junto, escondidos dentro de uma caixa de madeira embaixo de algumas roupas; questionada sobre as drogas, disse que eram para seu consumo pessoal e que alguém as tinha deixado ali; foram apreendidos todos os objetos de interesse às investigações e a indiciada conduzida até essa Unidade Policial para as providências de Polícia Judiciária pertinentes (fls. 07).

Em juízo, disse que: participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa da ré; houve denúncias anônimas de que no local estaria ocorrendo tráfico de drogas; o Conselho Tutelar informou que no local estaria ocorrendo também a venda de bebidas alcoólicas para menores que acabaram passando mal, o que está sendo apurado em inquérito a parte; constataram que estava ocorrendo o tráfico e foram cumprir o mandado, quando encontraram as drogas e apetrechos relacionados ao tráfico na residência; as drogas foram encontradas no guardar-roupas embaladas de forma individual; CELINA disse que as drogas eram para consumo pessoal; o Delegado acompanhou as buscas e como as drogas estavam devidamente embaladas e havia apetrechos, entendeu que estava caracterizado o tráfico; o local foi lacrado por conta da venda de bebidas sem autorização da Prefeitura; apreenderam a balança e o canivete porque é comum nos locais em que há tráfico a utilização desses objetos; apreenderam os objetos para serem periciados e verificar se havia algum resquício de substância ilícita; quem fez a campana foi o Setor de Investigação da Delegacia e, com base nas diligências, pediram o mandado de busca e apreensão; na casa havia um aparelho celular de terceiro, o qual foi identificado e foi intimado para comparecer na Delegacia e ele confirmou que deixou o celular "penhorado" pois era usuário de cocaína e comprava drogas com a ré.

A testemunha, José Antônio Lopes Pereira, policial civil ouvido em solo policial relatou que: é Policial Civil lotado na Delegacia de Polícia de Guapiara; na data em questão, com o apoio de Polícias Militares da cidade, se dirigiram até a Rua Major Justino Ferreira de Lima, nº 76, centro de Guapiara; as equipes foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela r. 2ª Vara da Comarca de Capão Bonito, nos autos nº1500305- 60.2022.8.26.0123; por volta das 08:45, chegaram até o local dos fatos; chamaram pela proprietária da residência; foram recepcionados pela Sra. CELINA DE OLIVEIRA, que teve ciência do inteiro teor do mandado e das razões daquela diligência; a ré acompanhou todas as buscas, foram vistoriados vários cômodos da residência; na cozinha do imóvel e na sala, estava armazenadas uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, copos descartáveis, canudos e outros utensílios; indagada a ré, informou que comercializa bebidas em sua residência, contudo não tem autorização da Prefeitura Municipal para funcionar, por tal motivo, fizeram contato com o setor responsável do órgão municipal que compareceu até o local e tomou as medidas administrativas cabíveis; ao vistoriarem o quarto da ré, localizei em seu armário alguns pinos de epeendorf, dentre eles alguns cheios com uma substância branca aparentando ser cocaína e outros vazios, próximo aos pinos, estavam escondidas algumas embalagens plásticas que são geralmente utilizadas para embalar drogas, além de uma máquina seladora de papel e um caderno com anotações; questionada novamente sobre as drogas a Sra. CELINA disse

ser usuária, apesar de existirem ocorrência formalizadas através do "disque denúncia" contra sua pessoa; ao final das buscas, foram apreendidas duas balanças de precisão, aparelhos de telefonia móvel, máquina de cartão, além de substância embaladas prontas para a venda com entorpecente do tipo maconha, esta encontrada pelo outro Policial Civil que ajudou nas buscas. (fls. 07).

A testemunha de Defesa, Mário Lino de Carvalho, em juízo disse que: não sabia do envolvimento de CELINA com drogas; a ré vive de vender salgadinho e "copão" (bebida); ela tem o "bar" há uns três ou quatro anos; ela é responsável por cuidar dos netos.

A seu turno, Hélio de Souza, também testemunha da Defesa relatou em juízo que: não sabe do envolvimento da ré com drogas; não sabe se ela usa droga.

Gleysla Myrelle de Oliveira Costa, filha da ré, ouvida em juízo disse que: sabe que a mãe usava cocaína; já fazia quase 2 anos que a mãe estava trabalhando com venda de bebidas.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal". (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente a ré, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório, tem-se que a ré confessou em juízo vender entorpecentes para sustentar o seu vício em cocaína.

A confissão da ré vai ao encontro das demais provas produzidas nos autos, sobretudo o depoimento da testemunha Fernando e o relatório dos dados extraídos dos celulares apreendidos (fls. 213-225), onde se verificam conversas sobre o tráfico de entorpecentes.

Com efeito, na residência de CELINA foram encontrados os entorpecentes indicados na denúncia, além de diversos objetos utilizados na traficância, como duas balanças de precisão, máquinas de cartão, dinheiro trocado, embalagens plásticas, seladora de embalagem plástica, eppendorfs vazios (fls. 20-22).

Portanto, há provas suficientes de autoria e materialidade do delito a justificarem a necessidade de responsabilização penal.

A ré, de forma consciente e espontânea, guardava e tinha em depósito para fins de entrega ao consumo de terceiros, 08 papéletes de maconha pesando 17 gramas, e 08 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 3,60 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Com isso, está preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. A ré agiu com dolo, nas modalidades cognitivas e volitivas, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, a ré possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse, de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dela era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação da ré CELINA DE OLIVEIRA nas penas do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida maconha e cocaína. Dois tipos de drogas reclamam a maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Em relação à quantidade, foram apreendidos 08 papелotes de maconha pesando 17 gramas, e 08 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 3,60 gramas. Não há no caso, desborde do tipo penal em razão dessa quantidade.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confirma-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros

constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, tendo em vista que as circunstâncias descritas no art. 42, da Lei 11.343/06 e 59, do Código Penal, somadas, totalizam dez distintas, a serem valoradas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceram-se quatro circunstâncias como negativas (a natureza da substância), a pena privativa de liberdade deve ser majorada em 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito.

Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal tais como acima consideradas, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Presente, entretanto, a atenuante da confissão. Atenuo a pena em 1/6 e fixo na fase intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento. Em relação à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, embora da ré seja primária e não ostente maus antecedentes, o depoimento da testemunha Fernando e as informações extraídas dos celulares apreendidos dão conta de que o comércio de entorpecentes era meio de vida de CELINA, que se utilizava como disfarce para a atividade ilícita a venda de salgados e de "copão" (aliás, também de forma irregular e com denúncias de que estaria fornecendo bebidas alcoólicas para menores de idade).

De acordo com Fernando, CELINA inclusive recebia bens em uma espécie de garantia para o comércio de entorpecentes. Um celular de terceira pessoa foi apreendido na residência. As imagens de fls. 217 demonstram a preparação de diversas porções de cocaína e as conversas inclusive indicam que CELINA negociavam armas (consta a referência a uma "380").

Não se trata, portanto, de uma atividade isolada. Há elementos suficientes que indicam verdadeira dedicação ao tráfico e outras atividades criminosas. Portanto, não faz jus à causa de diminuição de pena. Torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 5 anos de reclusão), o fato de a ré não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), fixo o regime inicial semi-aberto.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso a ré foi condenada a pena superior a 4 anos, não satisfazendo o requisito objetivo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP) ou para a suspensão condicional da pena.

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira da ré.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receiptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a

análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré CELINA DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

FIXO valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos. CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a ré foi condenada à pena a ser cumprida em regime inicial distinto do fechado.

Com efeito, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão de que custódia cautelar (e, portanto, provisória) seja cumprida de forma outra que não mediante o encarceramento da ré. Mantê-la custodiada, quando a pena definitiva a ele imposta é menos grave do que a segregação cautelar, implica em gestar nova modalidade de prisão processual, poder do qual não dispõe o magistrado.

Assim, concedo ao ré o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo não estiver presa.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos às fls. 20-22 por serem produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSCGJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-

- A, das NSCGJ;
- b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
- c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
- d) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
- e) Lance-se o nome da ré no rol dos culpados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA